

本案生效裁判采纳第二种观点。从表面上看，包某某为每个外国客户提供的服务内容具有类似性，但根据行为的对象不同，可以分为：针对需要非法入境的外国人和针对已经在境内需要非法居留的外国人两种类型。对象不同导致行为的手段、需要提供的证件、办理的手续上均存在差异，在是否有偷渡入境情节上也 有着关键的区分。从法益保护的角度来看，组织他人偷越国(边)境罪侵犯的是国家对进出国(边)境的管理制度，而出售出入境证件罪侵犯的是国家对出入境证件的管理秩序，两者侵犯了不同法益。本案中，根据是为境外外籍人员提供非法入境服务还是为境内外籍人员提供非法居留服务等情况，将包某某的行为区分为组织他人偷越国(边)境行为和出售出入境证件行为，在行为对象上不存在重叠交叉，也不存在重复评价需要择一重罪论处的问题，故依法应数罪并罚。但考虑两者在行为手段上存在一定的相似性，在量刑时可酌情从轻考虑。

编写人：上海市松江区人民法院 胡晓晖 钱莹 韩玲

(四) 危害公共卫生罪

36

刑满释放后再次非法行医且未造成实害后果和危险的亦应适用“其他情节严重情形”

——陈某某非法行医案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省宿迁市中级人民法院(2022)苏13刑终117号刑事裁定书

2. 案由：非法行医罪

【基本案情】

被告人陈某某曾在2013年8月7日、2014年9月16日因在未取得《医师资格证书》《医师执业证书》《医疗机构执业许可证》的情况下擅自开展诊疗活动，两次被给予行政处罚。后因再次非法行医，于2018年1月11日被江苏省宿迁市宿豫区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。2018年7月24日，被告人陈某某刑满释放。2020年9月1日，被告人陈某某又在未取得《医师资格证书》《医师执业证书》《医疗机构执业许可证》的情况下，明知自己不具备行医资格，仍在某地擅自非法开展针灸诊疗活动，被宿迁市卫生健康委员会当场查获。宿迁市卫生健康委员会以陈某某涉嫌非法行医犯罪而移送公安机关。

【案件焦点】

1. 仅查到一次诊治行为能否认定被告人陈某某实施非法行医行为；2. 被告人的行为是否应适用非法行医罪司法解释规定的“其他情节严重情形”。

【法院裁判要旨】

江苏省宿迁市宿豫区人民法院经审理认为：被告人陈某某在未取得医生执业资格的情况下，非法从事医疗活动，情节严重，其行为构成非法行医罪。被告人陈某某自动投案，在归案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十六条第一款、第六十七条第一款、第六十五条以及《最高人民法院〈关于审理非法行医刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条之规定，判决：

一、被告人陈某某犯非法行医罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元；

二、将扣押的针12支，予以没收，由扣押机关依法处理。宣判后，被告人陈某某提出上诉。

江苏省宿迁市中级人民法院经审理认为：上诉人陈某某在未取得医生执业资格的情况下，非法从事医疗活动，情节严重，其行为已构成非法行医罪。上诉人陈某某自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。上诉人陈某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。原审法院认定上诉人陈某某犯非法行医罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。江苏省宿迁市人民检察院建议驳回上诉，维持原判的意见正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

利益驱使或是谋生需要，部分行为人在因非法行医被刑事处罚后仍会继续非法行医，且方法会更加隐蔽，如未有门头、在雇用有执业资格的医生坐诊时穿插问诊、开处方不标注姓名、当日单据当日销毁等，加大了非法行医的查处难度。当未出现现实害后果时，卫生监督部门可能仅能查实当日或当时的行为，也就是说查实行为人诊治次数较少，甚至只有一次，我们首要界定行为人的行为是否为非法行医，再评判行为是否达到“情节严重”及适用情形，从而准确入罪追责。

一、被告人陈某某实施的针灸行为系诊疗活动，属于法律规定的非法行医

根据《最高人民法院关于审理非法行医刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，非法行医主要指未取得、非法取得、已取得被吊销或超范围从事医疗活动或医疗行为。因此，准确界定医疗活动或者医疗行为的内涵是认定非法行医的关键。本罪司法解释并未对“医疗活动”“医疗行为”的内涵作出解释，而是参照《医疗机构管理条例实施细则》中对“诊疗活动”“医疗美容”的认定。《医疗机构管理条例实施细则》第八十八条规定，诊疗活动，是

一、妨害社会管理秩序罪 155

指通过各种检查，使用药物、器械及手术等方法，对疾病作出判断和消除疾病、缓解病情、减轻痛苦、改善功能、延长生命、帮助患者恢复健康的活动。从条款字面意思角度分析，诊疗活动是执业医师运用有效方法对病人所患疾病作出诊断并以此给予诊疗方案，达到帮助病人消除疾病、缓解病情、恢复健康等活动，并未要求以对多人或多次实施行医行为作为认定诊疗活动的限制条件。简